

论中国法治评估的转型*

钱弘道 王朝霞

摘 要:近十年来,全国许多地方出现了各种探索法治评估的实践。总结法治评估实践经验,分析法治评估实践存在问题,判断全国法治评估走向,提出建设性思路,具有重要意义。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》出台后,法治评估在实践和理论两个方面面临转型。法治评估转型的重点在于法治评估的正确定位、法治评估机制的创新、法治量化难题的破解和法治评估经验总结 and 理论升华的实现。科学的法治评估机制是评估工作得以有效开展的前提,破解法治量化难题是科学评估的要害,法治评估经验总结 and 理论升华是评估实践提出的必然要求。法治评估机制创新重点在实施第三方评估模式,法治量化可从专项评估入手。

关键词:法治评估 法治评估转型 指标体系 考核标准 国家治理

作者钱弘道,浙江大学光华法学院教授(杭州 310008);王朝霞,浙江工业大学法学院讲师(杭州 310023)。

近年来,全国许多地方积极探讨或实施法治评估机制。法治评估体系、法治政府指标体系、司法公开标准等在实践中得到广泛应用,法治指数、司法透明指数、电子政府发展指数、司法文明指数、司法公信力指数、司法公正指数等指数化测评相继出现。时至今日,法治评估已然成为一项地方法治建设的“抓手”。对当前的法治评估,可根据不同标准进行分类。根据评估内容,可分为综合评估和专项评估。法治指数测评覆盖法治的主要维度,属于综合评估;立法评估、法治政府评估、司法透明指数测评、司法公信力指数测评等侧重法治的某个方面,属于专项评估。根据评估方式,可分为内部考评和第三方评估。目前,各地根据国务院指导性意见开展的法治政府考评、最高人民法院开展的阳光司法考评属于内部考评,浙江余杭法

* 本文系国家2011计划司法文明协同创新中心、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国法治政府建设指标体系研究”(13JZD011)、国家社会科学基金重点项目“司法透明指数研究”(13AFX012)阶段性成果。

治指数、吴兴区司法透明指数、杭州市电子政府发展指数、浙江全省 103 家法院阳光司法指数等指数类测评基本上属于第三方评估。根据评估对象,可分为省域范围内的地方区域性评估和跨省际、全国性评估。如中国社会科学院法学研究所国情调研室开展的政府透明度评估、中国政法大学中国法治政府研究院开展的法治政府评估,均属于跨省际、带有全国性特点的法治专项评估。^①

法治评估面临转型。当前,法治评估存在一些亟须解决的问题,至少表现在以下方面。其一,法治评估虽然成为一些地方法治发展的“抓手”和“增长点”,但也有些地方对法治评估的重要性缺乏认识。其二,一些已经实施法治评估的地方缺乏科学的评估机制,这突出表现在,套用内部政绩考核方式,停留在宣传层面,法治评估作为一项制度创新的效应没有得到充分发挥。其三,各地的综合评估或者专项评估,在一定程度上存在指标体系和考核标准科学性不足的缺陷。其四,法治评估缺乏理论指导。无论指标体系和考核标准的设计、机制创新,还是评估后的数据分析、问题应对,都缺乏及时的经验总结和理论升华。

法治评估转型的分界线是 2013 年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《改革决定》)和 2014 年《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《法治决定》)的出台。《改革决定》的时间设计到 2020 年,届时,在重要领域和关键环节的改革上将取得决定性成果。换言之,对中国发展的重要领域和关键环节来说,2013 年以前和从 2013 年到 2020 年,显然是两个不同阶段,法治评估也不例外。作为法治建设的一种有效机制,法治评估是《改革决定》和《法治决定》中的重要内容。《改革决定》提出“建立科学的法治建设指标体系和考核标准”,这对全国范围内的法治评估提出了总方向。在这个总方向下,法治评估的定位、实践机制、指标设计、理论导向都会出现带有转型特点的重要变化。《法治决定》将法治纳入考核,将从根本上改变领导干部的政绩观。把握《改革决定》确定的总方向、《法治决定》的法治考核精神以及法治评估转型的客观要求,促进法治评估转型顺利实现,就成为推进法治中国建设、实现治理现代化必须解决的重大任务。本文试图从定位、机制、量化以及理论升华几方面入手,分析法治评估转型的原因和路径,提出具有建设性、可行性的思路,以期推动法治评估在法治中国建设乃至整个国家治理体系和治理能力现代化中产生重要作用。

① 中国社会科学院法学研究所国情调研室 2010 年对 43 个较大的市和国务院所属的 59 个部门进行透明度测评。此外,中国政法大学 2011 计划司法文明协同创新中心开展的司法文明指数测评,中国法学会在部分省会城市、计划单列市试行法治指数的测评,均为跨省际评估,带有一定的全国性特点。真正、全面的全国性法治评估实践,仍处在探索阶段。

一、法治评估的正确定位

法治评估的转型,首先需要解决定位问题,即对法治评估地位的认识应取得共识。《改革决定》将法治评估与治理现代化紧密地结合在一起,促成了法治评估定位的转型。明确和理顺法治评估地位的重大变化、法治评估与国家治理体系的关系、法治评估与国家治理能力的关系、法治评估的功能及其在国家治理现代化中的作用,是正确定位法治评估的基本要求,也是把握法治评估转型的逻辑起点。

(一) 法治评估地位的重大变化

法治评估在中国经历了实验探索、推广、成为改革方向这样一个发展历程。其间,也经历了被质疑的阶段。学术界对法治评估的认识有分歧,各地对法治评估的实践态度也不一样。法治评估是伴随着疑问和质疑向前推进的。有“全国法治试验田”^①之称的余杭法治指数实验就曾引发争议。^②争论的结果是,法治指数得到普遍认同,并引领了司法透明指数、司法文明指数等各种指数的研究和实践。深圳较早探索法治政府指标体系,其后国务院法制办印发《深圳市法治政府建设指标体系(试行)》,供各地政府参考。浙江省高级人民法院最早尝试司法透明指数倒逼机制,其后最高人民法院印发全国各法院参考。《改革决定》出台以前,法治评估基本上处于一些地方自发创新的阶段,法治评估并没有完全取得共识。

《改革决定》提出“建立科学的法治建设指标体系和考核标准”,这就从顶层意义上明确了法治评估是实现治理现代化这个总目标的一种有效机制。法治评估的地位因此发生了根本性变化,这是法治评估转型的一个最明显标志。《法治决定》提出把法治纳入政绩考核,作为提高党员干部法治思维和依法办事能力的重点措施,这是对法治评估转型的一个重大诠释。由此,全国各地进入必须贯彻《改革决定》和《法治决定》、深入开展法治评估的新阶段。

根据《改革决定》提出的全面深化改革的总目标“完善和发展中国特色社会主

① 2008 年,司法部副部长张苏军到余杭开现场办公会,称余杭为“全国法治试验田”,余杭“全国法治试验田”因此得名。

② 2006 年,时任浙江省委书记的习近平同志力推“法治浙江”,杭州市余杭区在全国率先启动以法治指数为枢纽的“法治余杭”工程。余杭实验催生了“司法透明指数”、“电子政府发展指数”等法治分类指数,在理论界和实践中产生了重要影响。余杭法治指数因此入选“浙江省改革开放 30 年百件大事”。(参见陈耿忠主编:《区两个案例入选省改革开放 30 周年百件典型事例》,杭州市余杭区地方志编纂委员会编:《余杭年鉴(2009)》,北京:方志出版社,2009 年,第 64 页)

义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”，法治评估的认知和定位必须置于“国家治理体系和治理能力”这个角度。《改革决定》出台前，法治评估与国家治理体系、治理能力之间的关系未能得到有效链接和充分阐述。推动法治评估转型的第一步，需要将法治评估与国家治理体系、治理能力统一起来。这种对法治评估地位的认知转型基于下述逻辑和理由。

首先，法治评估与治理现代化的关系是由法治和治理现代化的关系决定的。

中国已经从国家统治、国家管理演变到国家治理阶段，“治理”成为普遍认同的概念。这个演变不单是表述和概念的更替，本质上是一种国家治理理念、治理方式的进化和变革。^①与统治相比，治理是更高层次的社会管理形式。它的基础不是控制而是协调，是多元权力（权利）的持续互动、信任合作与协调平衡。^②现代国家治理强调在公权力限制与私权利保护中体现政府与民众的友好互动与合作，其内涵直指法治的内核，体现了对法治化治理方式的推崇。《改革决定》第一次在顶层设计的意义上提出“国家治理体系”和“治理能力”的概念，并作为改革总目标，第一次专门将“推进法治中国建设”单列。法治中国实际上成为国家治理体系和治理能力现代化工程中最关键的内容。而法治评估作为法治建设的增长点，已经在立法评估、法治指数测评、法治政府评估、司法透明评估等实践中得到有力证明。由此，法治评估是中国治理观念变革的直接产物，是治理现代化的逻辑延伸。

其次，法治评估的内容是国家治理体系、治理能力的核心组成部分。

国家治理体系和治理能力两部分构成国家治理的内容。国家治理体系是制度层面的，治理能力是执行层面的。“国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现。”^③作为一个制度体系，国家治理体系包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排。在各领域体制机制、法律法规安排中，以《宪法》为统领的法律体系是最核心的制度安排。法治考核标准则是对法治中国建设的纲要、目标、要求进行更细化、具有可操作性的量化设定。“科学立法”是法治中国指标体系的第一个维度。法治评估、法治指数本身是一项制度创新，它把各种法律规定用量化的指标形式体现出来，作为法治工作的一个指南、指针和标准，是通过法治联结在一起的制度，是关系到整个法治中国的一项制度创新实验。^④

国家治理能力是“运用国家制度管理社会各方面事务的能力，包括改革发展稳

① 参见何增科：《理解国家治理及其现代化》，《马克思主义与现实》2014年第1期。

② 参见俞可平主编：《治理与善治》，北京：社会科学文献出版社，2000年，第9页。

③ 习近平：《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》，《人民日报》2014年1月1日，第2版。

④ 参见钱弘道主编：《中国法治实践学派》，北京：法律出版社，2014年，第199—201页。

定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面。”^① 这种能力核心的体现是法治能力。所谓法治能力，是治理主体运用法治思维、法治方式的水平。这就要求“严格执法”、“公正司法”。“严格执法”、“公正司法”分别是法治中国指标体系的第二、三个维度。

国家治理达到理想的效果是“善治”，其重要标志是“全民守法”。“全民守法”既是治理过程中的要求，也是治理结果的一种状态，是法治中国指标体系的第四个维度。

法治评估内容和国家治理体系、治理能力在上述逻辑中得到了有机统一。要言之，所谓国家治理体系和治理能力现代化，就是使国家治理制度化，使国家治理者善于运用法治思维和法治方式治理国家。

综观国内外的评估指标体系设计，法治评估和治理评估互为表里，仅内涵外延不同而已。在西方发达国家和一些国际组织开展的衡量一国或全球多国治理水平的评估体系（以世界银行的全球治理评估为代表）中，法治指标是核心部分。^② 在国内一些专家学者开展的中国治理评估体系研究中，法治指标，以及与法治相关的如公民参与、人权与公民权、合法性、社会公正、政务公开、政府责任、廉洁等都被作为主要的国家治理评估要素。^③ 国内外所有的法治指标体系都直指国家或地区的治理水平。例如，余杭法治指标体系的9个一级指标——党委依法执政、政府依法行政、司法公平正义、权利依法保障、市场规范有序、监督体系健全、民主政治完善、全民素质提升、社会平安和谐基本上概括了地方治理的核心内容。由一级指标分解出来的二级指标和更细化的考核标准则更突出体现中国内地县区的具体治理状况。

（二）法治评估的治理工具功能

法治评估本质上是一种治理工具。^④ 法治评估对于治理现代化，发挥着一种治理工具的作用。这种作用类似于现代管理学中的绩效评估与绩效管理的关系。《法治决定》将法治纳入政绩考核，正是治理工具观念变革和绩效管理创新的突出表现。政绩考核体系的转型使法治评估定位得以具体化，使法治评估作为一种观念嵌入人们尤其是领导干部的头脑，作为一种治理工具进入绩效管理体系，通过用法治思维

① 习近平：《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》，《人民日报》2014年1月1日，第2版。

② 参见 <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp>, 2014年7月3日。

③ 参见俞可平主编：《国家治理评估——中国与世界》，北京：中央编译出版社，2009年，第12—15页。

④ 20世纪80年代以来，政府工具理论成为西方公共管理和政策科学研究的一个焦点。（参见陈振明：《政府工具研究与政府管理方式改进——论作为公共管理学新分支的政府工具研究的兴起、主题和意义》，《中国行政管理》2004年第6期）

和法治能力衡量领导干部素质,从而实现对法治评估地位的认知转型。

绩效评估作为一种管理方式,其作用在于推动绩效提升,从而实现管理的现代化和科学化。随着现代管理学的科学管理理念、技术和方法的渗透,国家治理也开始迈向科学治理时代。^①国家治理的现代化,其关键就在于科学治理。科学治理要求精细化、过程管控、绩效追踪和反馈,其本质是高效能、高绩效。运用运筹学、统计学等原理,采用指标体系和运算模式,按照合理的程序和方法,以量化形式对国家治理状况做出全面的、系统的客观评估,对治理水平进行实时、动态、科学的管控、监测、诊断、反馈,以减少治理的盲目性。法治评估的工具性作用正是通过这样一种治理绩效评估体现出来的。

法治评估通过量化形式促进国家治理的精准化、精细化。长期以来,我们对于国家治理的成效停留于思辨式的、质性的追问,难免粗糙。而法治评估借助量化工具使我们得以进入一个诊断相对精准的时代。法治评估这一功能的发挥,体现了自身固有的工具特性。近年来,国内外法治评估的探索和实践不同程度地反映了这种特性。在世界正义工程 2011 年的全球法治指数排名中,在九个维度满分为 1 的情况下,中国得分普遍在 0.5 分以上,各指标处于中等水平。^②余杭自 2007 年开始,历年的法治指数依次为 71.6、71.84、72.12、72.48、72.56、73.66、71.85 分。^③这些数字的背后是大量的数据链,正是这些数据相对客观地反映了一个国家或地区的治理状况以及问题症结。尽管我们不能陷入“唯数字论”,但量化的、力求客观的精准式管理一定优于主观的、粗糙式管理。从这个意义上来说,法治评估将国家治理从传统的经验式引向以科学为宗旨的现代化阶段。

法治评估促进国家治理形成完整的工程系统。科学化的治理,既包括目标的事先规划,即战略性治理、目标导向的治理,又包括对整个治理过程的管控。治理结果是静态的,治理过程是动态的。只有同时关注结果与过程,才能发挥治理目标的引领作用,及时矫正治理过程中的失误和对目标的偏离。法治评估作为一种国家治理现代化的治理工具,在设计指标阶段,往往将国家治理的目标和要考察的治理过程联系起来。法治政府指标、司法透明指标、司法公正指标,通过系统考量,自上而下地对总目标进行逐层分解,对治理目标进行规划。进入后期的评估实施阶段,

① 绩效管理和科学管理的概念来自于管理学。治理与管理这两个概念在学科层面上,按照学科的表述习惯混同使用,通常认为二者为同义。这有别于前文对国家管理和国家治理的区分。

② 参见张保生、郑飞:《世界法治指数对中国法治评估的借鉴意义》,《法制与社会发展》2013 年第 6 期。

③ 参见法治余杭课题组:《杭州余杭法治指数报告》,中国社会科学院法学研究所编:《中国法治发展报告 No.9 (2011)》,北京:社会科学文献出版社,2011 年,第 386—403 页;钱弘道等:《法治评估的实验》,北京:法律出版社,2013 年,第 241—256 页。

各项指标或考核标准被逐一赋值,反映其所代表的治理水平的高低或者治理状态。这个阶段突出的是对治理过程和结果的考察、测评和分析。法治评估由此完成对国家治理的“目标—过程—结果”三阶段的全面、动态考察。这种考察将国家治理的全部链条进行整合,形成首尾相接的工程系统。

(三) 法治评估的民主参与和监督功能

法治评估有一个突出的功能,就是公众的民主参与和监督。这项功能是传统的政绩考核模式所不具备的。这项功能没有被充分认识,实践中也没有得到有效发挥。要实现法治评估转型,就必须在这个问题上有足够的共识。

国家治理体系和治理能力现代化的目标,归结起来就是要实现善治。公民是否能参与国家治理,有效监督国家治理的过程,是衡量善治的标准。公权和私权达到均衡的状态就是善治。公权与私权绝对均衡的状态虽然不可能实现,但可以最大程度地接近。这种均衡主要依赖于民主参与的模式。实践表明,群众路线是改革成功的保证,国家治理必须走群众路线,必须注重民众经验。群众路线应该主要强调听取群众的意见,让群众参与到国家治理中来。

国家治理的绩效须通过社会的认可和建构才能得以形成。^①缺少社会公众参与或者由政府单方面形成和公布的评估结果,即使内容再充实也不足以反映治理绩效的真实情况。^②从这个意义上说,收集公众对国家治理的感知信息至关重要,它有助于争取外部公众对政府的信任和支持,是强化问责机制的重要途径。法治评估作为一种参与机制、监督机制、倒逼机制,能促进公民参与和监督国家治理机制的形成,从而实现善治目标。

在我国地方法治评估实践中,余杭法治指数、杭州市电子政府发展指数、吴兴区法院司法透明指数、浙江省阳光司法指数、昆明法治指数、国家 2011 计划司法文明协同创新中心的司法文明指数等,均通过实地和网络调查、专家和实践工作者积极参与等测评方式,体现民主参与和监督功能。

实践表明,法治评估的这种公众参与和监督功能是有有效的。例如,浙江余杭每年公开发布法治指数,客观上形成了一种压力和监督力量。2014 年,余杭垃圾焚烧项目事件是一个典型例子。2013 年余杭法治指数为 71.85,比 2012 年的 73.66 有明显跌幅。这给余杭区政府带来了更大的压力,进而形成监督力量,倒逼余杭政府在

① Laurence E. Lynn, Jr., Carolyn J. Heinrich and Carolyn J. Hill, "Studying Governance and Public Management: Challenges and Prospects," *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 10, no. 2 (April 2000), pp. 233-261.

② 吴建南、杨宇谦:《地方政府绩效评估创新:主题、特征与障碍》,《经济社会体制比较》2009 年第 5 期。

处理垃圾焚烧项目过程中运用法治思维和法治方式。从这个意义上讲,法治评估活动创造了一种公众参与治理、监督公权力的模式,拓展了民主参与渠道,使公众在国家治理法治化和治理能力现代化中的作用得到有效发挥。这种民主参与和法治化治理,正是国家治理现代化的落脚点。

二、法治评估机制的创新

科学的法治评估机制是评估工作有效开展的前提。《改革决定》和《法治决定》出台以前的法治评估,得益于部分地区和领域的领导远见和法治创新魄力。法治评估仍然主要表现为传统的政绩考核模式,没有跳出“自己人考评自己人”的程序窠臼,“第三方评估”模式仍处于实验阶段。政府在法治评估中的角色定位模糊。人们对法治评估的权威性、公信力持有疑虑。由于缺乏高层推动力,法治评估的局部实验也没有对其他地区形成足够的压力和竞争,法治评估对全国法治建设的推动尚未产生理想效果。《改革决定》和《法治决定》出台以后,法治评估成为一种从上至下的改革要求,法治评估实践的格局将出现重大转型。法治评估机制的转型或创新,至少表现在评估模式、责任制、竞争机制三个方面。

(一) 法治评估模式

中国法治评估模式正在从内部考评向第三方评估转型。法治评估模式的创新重点在如何实现真正的第三方评估。

内部考评模式是一种传统的常规方式,目前各地的法治政府评估大都属于内部考评。内部考评缺乏独立性,公信力低,被考核对象容易陷入“既是裁判又是运动员”的角色冲突中去,局限性较为明显。

国际上通行第三方测评各类指数。随着世界范围的社会指标化运动的兴起和发展,中国也出现了第三方评估模式。最早采用第三方法治评估的是余杭法治指数测评。从当前法治评估实践可以发现,高校科研机构发挥了重要作用,并且扮演了“第三方”的角色,如余杭实验委托浙江大学和中国法治研究院组织实施,浙江省高级人民法院委托浙江大学开展阳光司法指数课题研究,并委托中国社会科学院法学研究所测评阳光司法指数。

在法治评估机制转型阶段,评估模式的特点是内部考评与第三方评估将同时并存。作为一种管理方法,内部考评在实践中仍有积极意义。法治评估进入成熟阶段,内部考评依然会作为一种管理方法存在。特别是在“政府主导”法治建设的转型期,官员的法治思维和法治能力的培养是一个重大任务,政府内部考评有其不可否定的作用。但是,第三方评估是法治评估的必由之路,也是法治评估成为治理现代化增长点的关键所在。目前,第三方评估以政府委托为主,这是由实际情况所决定的。

其一,协同创新已成为法治实践和理论创新的一种模式;^①其二,中国缺乏民间评估组织,即便是大学、科研机构,也受制于资金条件限制。这里的难题是如何确保第三方独立公正,政府不干涉评估。

当前,比较可行的是发挥更多的大学、科研机构担当第三方评估的角色。中国公众参与国家治理和社会事务还不成熟、不充分,学者发挥牵引作用,作为联结政府与公众的桥梁,是一种可行模式。在未来法治评估机制转型和优化过程中,应明确学者与政府的关系定位,逐步扩大专家学者的参与程度,在学者的独立性和其与政府的契合性之间寻求最优化模式。

从长远看,中国的第三方评估模式还有赖于社会组织和公民的有序参与。这就涉及《改革决定》、《法治决定》提出的“法治社会建设”问题。^②社会组织担任第三方评估的角色,是《法治决定》提出的“发挥社会组织在法治社会建设中的积极作用”的具体表现。当第三方评估成为中国法治评估的基本模式、内部考评走向科学化时,法治评估才会基本完成转型,治理现代化的目标才会初步实现。

(二) 法治评估责任制

前述评估模式强调第三方的作用,法治评估责任制则强调政府和官员的责任。

从当前法治评估实践看,政府的主导作用影响全局。一方面是政府的顶层设计,如国务院出台《全面推进依法行政实施纲要》,国务院法制办研究推出《关于推行法治政府建设指标体系的指导意见》等都直接推动了全国各地法治政府评估活动的开展。^③另一方面是地方政府先行先试。时任浙江省委书记的习近平同志倡导“法治浙江”,余杭及时推出法治指数实验。从设立法治评估研究项目,到委托研究、参与研究、制定评估体系,再到委托第三方测评法治指数,法治指数实验的整个过程都有政府组织参与。

“一把手”是个关键变量,这是当下地方法治建设的一个突出特点。各地法治建设的重视程度、方式差异、发展快慢与“一把手”的作用密切相关。这一点可以从余杭实验中得到证明。当学者提出制定法治建设指标体系和考核标准、测定法治指

① 参见钱弘道:《中国特色社会主义法学理论根植于实践》,《法制日报》2014年10月25日,第3版。

② 关于法治评估与法治社会建设的关系,参见江必新、王红霞:《法治社会建设论纲》,《中国社会科学》2014年第1期。

③ 如在省级层面开展法治政府建设指标体系的包括北京市、湖北省、广东省、江苏省、四川省、广西壮族自治区、江西省、河北省等,市一级层面的有深圳市、青岛市、惠州市、苏州市、温州市、德阳市、三亚市、渭南市、万源市、湘潭市等,区县级层面涵盖杭州余杭区、青岛市南区、苏州吴中区、河北永年县、深圳宝安区、贵州普安县、江西修水县、温州鹿城区、江西玉山县、南宁兴宁区等。

数的建议后,中共余杭区委的“一把手”起到关键作用。^①新的“一把手”接任后,在推进法治评估中也起到关键作用。^②

从“政府主导型”的法治发展模式和“一把手”这个关键变量可知,建立法治评估责任制在法治评估机制转型和创新中极其重要。建立责任制的前提是观念转型。此外,还需要相应的组织架构。从中央到地方应当建立专门的权威性法治建设领导机构,负责推进包括法治评估在内的各项法治建设工作。建立全面的法治责任制,并将与法治评估相关的内容纳入其中。

法治评估责任制要将所有领导干部的法治水平纳入干部考核机制,并将“一把手”作为考核重点,执行《法治决定》的规定:“党政主要负责人要履行推进法治建设第一责任人职责。”干部法治水平的考核应当包括法治思维、法治方式、法治能力、法治气质等法治素养指标,并且作为干部升迁奖惩的主要依据,要在选人用人的实践中认真贯彻落实《法治决定》的要求:“在相同条件下,优先提拔使用法治素养好、依法办事能力强的干部”。

在此,应注意如何避免法治评估责任制实施形式化。法治评估责任的落实必须避免以往政绩考核弊端,不应单纯依据政府内部形式化考核结果。要充分采纳第三方的评估结果。可以探索更大范围的民主化测评方法,由公众给出评价,这种民主化的法治评估责任制有益于党委、人大、政府、司法等法治主体责任的有效落实。民主党派作为参政议政的重要力量,有人才聚集优势,应当在领导干部考核中发挥作用,民主党派在用人方面的监督作用也因此名副其实。

(三) 法治评估竞争机制

从中国法治特点看,法治存在一种地方竞争的客观基础。这个基础表现为法治的地方创新现象。一些学者对此展开了研究,赞同“地方法治”这个提法。^③法治的地方竞争是由中国政治格局所决定的。法治的地方化,也就是法治的地方建设,本质上是贯彻中央精神的一种地方努力。这种地方努力不允许超越中央权力,但可在《宪法》范围内进行法治创新。地方政府可以根据《改革决定》和《法治决定》,甚至超越两个《决定》,展开法治竞争。地方竞争现象正是建立法治评估竞争机制的基础。

从实践看,法治评估基本上表现为不同程度的竞争模式。国务院法制办确定法

① 时任余杭区委书记何关新采纳学者建议,设立“余杭法治评估体系研究”课题,决定委托第三方测评法治指数。

② 接任余杭区委书记的朱金坤重视运用法治评估机制和法治指数测评,继续委托第三方测评法治指数。

③ 参见付子堂、张善根:《地方法治建设及其评估机制探析》,《中国社会科学》2014年第11期。

治政府评估导向,在全国范围营造了一种竞争状态。各地的自发实践也是一种竞争,是与所在省市的其他同级区域,以及中国范围的其他同级区域之间的一种竞争。例如,浙江省吴兴区法院的司法透明指数实验,是为了与浙江省乃至全国的地方法院竞争,因为最高法院建立了“司法公开示范法院”的竞争机制,为推动地方法治建设提供了动力源。

既然法治评估上表现为一种竞争机制,那么就有必要使其成为一种良性、科学的竞争机制。既有的法治评估,往往局限于一时一地,评估结果孤立、零散、碎片化,无法从时空序列上进行横向和纵向的法治水平比较,这限制了法治评估对法治建设的推动作用。因此,根据《改革决定》和《法治决定》对法治评估提出的要求以及法治中国建设的总体布局,建立具有横向可比性的竞争机制,就显得十分必要。这种竞争机制的建立有助于清理过多的绩效考核机制,避免各自为战,工作交叠,浪费资源,法治评估实践因此实现转型和优化。

在创新法治评估竞争机制过程中,要鼓励以法治评估为内容的“试验田”这种有效的竞争机制。^①贯穿于中国现代化发展及社会转型过程中的“试验田”机制,本质是一种试错机制、一种局部先行的非均衡式发展机制、一种从局部到整体逐步推进的竞争机制。这种机制已被实践证明是可靠的、适合中国发展需要的。《改革决定》和《法治决定》出台后,“知识产权法院试点”、“与行政区划适当分离的司法管辖制度试点”等更多“试验田”模式将在法治领域出现。

三、法治量化难题的破解

法治评估转型的核心任务是《改革决定》提出的建立科学的法治指标体系和考核标准。^②法治指标和考核标准是关于法治评估的讨论中最引人关注也是颇多争议的问题。建立科学的法治指标体系和考核标准的难题是如何量化,即解决“科学性”、“客观性”的问题。当然,法治评估过程中数据的获取、指数的计算以及数据的分析等都属于法治的量化问题。法治评估最大的特色就在于量化方法在法治领域的运用。能否破解量化难题,就成为实现法治评估顺利转型的关键。

① “试验田”通常表现为一种理性的实践,是成本最小化、效益最大化的机制,也常常因为激发实验者积极性而产生各种制度创新。

② 指标一般由指标名称和指标数值两部分组成,它体现了事物质的规定性和量的规定性两方面特点。《改革决定》将“指标体系”和“考核标准”并列,并非意味着两者是截然不相关的内容。法治指标是指经过权重分析、层层分解出来的目标和任务,考核标准是指对分解出来的指标进行量化分值。

（一）指标标准的顶层设计和地方创新

《改革决定》提出建立科学的法治指标体系和考核标准后，学界开始探索建立一个全方位的“法治中国建设指标体系和考核标准”。问题是，在中央层面上，是否有必要建立一个“法治中国建设指标体系和考核标准”？法治指标体系和考核标准的建设既需要顶层设计，也需要地方创新。

此处讨论的法治评估，既指法治的综合评估，也指立法、执法、司法等各领域的专项评估。法治指标是一个体系，涉及各个领域对法治目标的理解和定位。既有的法治评估，无论是法治的综合性评估，还是专项评估，都不同程度地存在定性、定量不够科学的缺陷。这是法治评估初创时期的阶段性特点。例如：法治指标尚未达到精耕细作；指标设计追求大而全，种类繁多，可操作性差；法治指标的表述往往不是对法治某一原则下关键要素的具体内容进行客观描述，仍然停留在法治的价值和意识形态层面；民意调查问题模糊，调查问题范围宽泛，令被调查者难以准确把握量化打分，影响民调效果，等等。这些问题得不到妥善解决和优化，法治评估的量化特性在指标设计环节就无从体现。

笔者认为，有必要由中央出面，成立法治指标体系和考核标准课题组，展开专门的深入研究。法治指标体系和考核标准涉及各个领域的法律法规，比一般的部门法立法难度更大，应该有长远的统筹计划。有必要尽快出台中央层面的关于法治建设和考核标准的指导性意见，给出法治中国建设指标体系的基本框架，制定初步的对领导干部进行考核的法治考核标准，供各地参照执行，今后逐步完善。

关于法治中国建设指标体系的基本框架，应当围绕《法治决定》确定的全面推进依法治国的总目标——建设中国特色社会主义法治体系进行设计。其核心内容表现为贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。《法治决定》是制定法治中国建设指标体系基本框架最好的依据。

短时间内，一步到位，立刻制定并实施全国统一的、完善的法治建设指标体系和考核标准并不现实。可行的办法是由中央牵头或者由中央委托的课题组对法治建设指标体系和考核标准进行深入研究，同时鼓励地方积极创新。中央的指导性意见是法治指标体系的顶层设计，内容可包括一级、二级指标框架，主要是根据宪法法律规定，根据《改革决定》和《法治决定》内容，根据中央有关精神，对法治建设目标、要求进行高度凝炼和概括。地方法治建设指标体系设计必须紧紧围绕中央指导意见进行。这样，可确保全国法治建设一盘棋式推进。但在贯彻中央指导性意见的前提下，要充分发挥地方的创造力，鼓励地方政府根据省、市、县、乡镇、社区

农村的不同层次和不同情况,进行实验。这样,地方法治建设指标体系是中央指导性意见的细化,尤其是考核标准,鼓励各地先行先试。从中央到地方的各级法治部门系统可依据顶层设计的指导意见,开展本领域的专项评估指标和考核标准的设计。中央层面的顶层设计课题组要跟踪研究各地先行先试的实践,系统分析,总结经验,条件成熟时研制推出全国性的法治指标体系和考核标准。

尽管很多地方开展了法治评估实践,但仍有一些地区至今没有尝试法治评估实践,没有开展对法治指标和考核标准的研究。如果中央及时推出指导性文件,这些“后发地区”应当及时贯彻落实中央的指导精神实施法治评估。已开展法治评估的地区和部门系统,应根据中央精神及时调整指标和标准,同时保留自己特色,继续深化评估实践,继续创新。随着法治实践的发展和研究的深入,法治指标体系和考核标准将会越来越科学。

(二) 法治量化的争论和共识

法治评估的量化方法有一套完整的操作技术,如抽样方法、资料收集方法、数字统计方法等。这一方法强调客观和中立的实证主义方法论立场,将法治评估指标简约为数字和数字之间的关系,强调运用统计分析方法对法治状况进行测评和分析,从中找出法治发展中的问题,并研究对策。^①然而,对法治量化问题的认识一直存在分歧。法治指数一经提出,学术界就展开了持续的讨论。讨论的焦点,集中在“法治是否能够被量化”这个问题上。一些学者提出,以分值、百分比、指数等构成的数字化、量化表征在多大程度上是可信的?数值的高低在多大程度上能够反映出法治的实际水平?指数的计算方法是不是科学的?原始数据是否可靠?法治评估是否能够做到完全量化、绝对量化?他们认为,法治不能量化的主要理由是法治定义本身的不确定性。我们认为,不能因为法治定义的不确定性就否定法治的可量化性。法治的界定不需要也不可能千篇一律。某些对法治的理解不能量化,不意味着法治绝对不能量化。

围绕法治量化的分歧和争论,反映出传统法学与现代法学研究思维和方法的交锋。在法学研究中,逻辑推理、规范演绎、形而上思辨是传统的研究方法,而用量化方法描述法治现象、分析法律问题,是新兴的研究方法。传统的规范法学研究范式对法学家的影响,持久深远、根深蒂固。一些法律学者从绝对量化意义出发理解法治量化,误以为法治量化应像衡量经济发展那么精确。法律现象不同于自然现象,因而法治的量化和客观性也是以特定方式呈现出来的“相对的客观性”,而非“绝对客观性”。从法治评估实践看,法治量化需要理顺两个方面的问题。^②

① 参见文军、蒋逸民主编:《质性研究概论》,北京:北京大学出版社,2010年,第21页。

② 参见姚建宗:《法治指数设计的思想维度》,《光明日报》2013年4月9日,第11版。

第一是真实和虚假的问题。这个问题主要是关于评估数据的真实性的问题。例如,在余杭实验中,法治数据的获取既有来自官方的统计数据,也包括通过社会调查方法获取的数据。来自官方的统计数据,是指各单位各部门在法治建设中与法治相关的各种数据,这些数据可以反映法治某方面的情况。这些通过多渠道搜集可供评估主体参考、作为赋分依据的法治数据是客观的。这里涉及的问题是,这些法治数据是否真实。一些人担忧政府提供的数据往往有人为成分,但在目前,如果不靠政府提供,这些数据就很难获取。

第二是绝对和相对的问题。余杭从 2007 年度法治指数的 71.6 分开始,每年的指数都小幅上升。这些数字是否准确反映其年度法治水平?这里有一个关于法治指数绝对性和相对性的认知问题。法治指数不可能是绝对准确的,只能是相对的,其作用主要是对不同国家或地区在不同年度的法治状况进行比较,也用作对同一个国家或地区不同年份法治状况的比较。我们可选取一些客观数据直接计算法治指数,^①但这种方法由于抛弃大量不可量化或者有正负两种性质的数据(如反腐败数据既反映反腐败的力度,也反映腐败的严重程度),计算结果仍然是相对的。

《改革决定》和《法治决定》对建立法治指标体系和考核标准以及法治纳入政绩考核体系作出明确规定,对形成共识意义重大。法治评估的转型,实际上也是在法治量化问题上的分歧减少、共识增多的过程。围绕法治量化问题,争论会继续下去,但随着理论研究和实践的逐步深入,共识会越来越多。

(三) 法治量化问题解决的可行途径

法治评估的转型,将突出地表现在法治量化难题的克服上。在多大程度上解决“法治不可量化测评”的质疑,将关系到法治评估的科学性和实效问题。

目前,国际上的量化评估项目及法治评估实践可分为两种模式:一种是主观和客观兼顾的量化模式,另一种是相对完全量化模式。

第一种模式以世界银行全球治理评估为例。在世界银行全球治理指数中,对法治这一下位变量的指标设计采用定性和定量相结合的方式。具体测评工作中的数据收集采用问卷调查方式。法治指标广泛容纳多家代表性机构对法治的多样化管理解,是一种主观的方法。由此设计出的法治指标涵盖内容宽泛,包括犯罪、警察、司法、政府效能、知识产权等法治的全貌,既有主观性指标也有客观性指标。在这些不同类型指标数据的搜集中,依据的是来自 30 多个不同组织机构提供的信息。这些数据通过专门设计的调查问卷搜集,其中既包括客观数据,又包括私营部门、非政府组织

^① 如司法透明指数和电子政府发展指数就是选取客观数据直接计算法治指数,完全做到了客观化和量化。这两种指数量化方法值得深入研究和借鉴,但仍然存在认识论的“相对性”的问题。

和公共部门专家的意见,因而兼具主观性和客观性。在整合不同数据源获得的同一个指标的不同数据时,世界银行采用“不可观测模型”法,以确保指标数据更为精确。

第二种模式以联合国电子政务发展指数为例。全球电子政务发展指数是衡量各国政府利用信息交流技术提供公共服务意愿和能力的综合指数。这一总指标包括在线服务指数、通信设施指数、人力资本指数三个分项指数。每个分项指数都再分解为若干个客观性指标,这些客观性指标各有其直接对应的数据,由此实现对各国电子政务水平的完全量化评估。这是一种接近完全量化的评估模式,但三个客观性指数的量化过程存在差别。如在线服务指数的计算是由专业测评员对国家网站的内容、特征及网页的可读性进行量化赋分,包括四个阶段的评估问卷。每个阶段的表现都有具体的分值区间来表示,绝大多数问题都要求在 1 和 0 两分区间中得以评估。

目前,这两种不同的评估模式在国内均有体现,且根据我国法治发展进行了改造创新,较为典型的可以测评法治指数的余杭模式为例。

余杭的法治指标和考核标准是从定性逐步转化为量化指标的。这个转换过程可分为一次量化方法和二次量化方法。一次量化指的是对某些客观性指标,可以一次实现从定性到定量的设计,如“造成错案冤案等重大责任事故数”、“纪委监察局工作人员违法违纪案件被查处数”等。二次量化指标通常不能一次性实现量化,而是需要层层分解、逐步实现。以依法行政为例,在依法行政指标体系中,先定性设置“转变政府职能,创新管理方式”、“完善决策机制,强化制度建设”、“规范行政执法,加强执法监督”三个定性的一级指标,此后细化分解为 12 个二级指标,其表述相对于一级指标更为具体。在设置权重的过程中,运用德尔菲法。^①最终,法治的每个指标都展示为考核标准的数字形态。

法治评估涉及主观与客观的问题。通常,人们以为法治量化应当是完全客观的,但实际上,余杭模式、吴兴模式以及国际上的法治评估都是主观与客观的结合。比较而言,电子政府发展指数、司法透明指数客观性更强。电子政府发展指数、司法透明指数是量化测评的有效模式,这两项评估的客观性体现在:将指标和标准统一,形成一个分指数的概念;各分指数又有其各自的子指数及由此形成的计算公式;所获得原始数据都是直接可用来计算的,且指数化的计算不再像法治评估中那样由评审主体主观打分。^②根据上述实践经验,法治量化测评可行的途径是综合采用如下两种方式:第一,采用国际上通用的民调方式;第二,通过大量专项量化指标评估法治状况。通过民调指数和专项指数的综合测评,所得出的法治指数是相对客观的。随着

① 参见何俊德编著:《项目评估——理论与方法》,武汉:华中理工大学出版社,2000年,第36页。

② 参见钱弘道:《中国信息公开的实证考察——中国法治实践学派的实验》,《中国法治实践学派》,第40—50页。

评估实践的推进,法治量化将逐步得到跨学科的深入研究,结果会越来越科学化。

四、法治评估的理论升华

2013年《改革决定》出台前,法治评估虽然表面上看起来已成为法学研究热点,但主要停留于地方实验、试错阶段。学界处于总结地方法治评估实践、研究世界上的法治指数的初始阶段,法治评估的理论文章开始出现,但为数不多。《改革决定》和《法治决定》出台后,明确了法治实践的方向和法治理论创新的重大任务,法治评估的经验总结和理论升华成为中国法治评估转型的题中之义。如果不能及时总结法治评估实践经验,并且上升为理论,如果缺乏科学的法治评估理论指导,法治评估的实践转型就难以实现。

(一) 创立法治评估学

法治评估实践产生以前,中国法治理论中根本不存在法治评估理论,甚至根本没有“量化法治”、“法治指数”、“法治评估”、“法治指标”、“司法透明指数”、“司法公信力指数”等词汇。

法治评估不仅产生了实践层面的重大意义,也为学术研究增添了一个新的研究领域,为理论研究提供了丰富、真切的现实素材,引发了一场以法治评估为切入点的关于评估技术、法学研究范式、中国法治、政府转型、国家治理等多学科、多领域相关问题的大讨论。这种讨论必然推动法治评估的理论升华。法治评估理论也是中国特色社会主义法治理论的组成部分。

法治评估理论有多种表现形式,如法治指数理论、立法评估理论、司法透明指数理论等。法治评估学是各种法治评估理论表现形式的基础理论。因而,法治评估学的创立是法治评估理论升华的首要表现。

法治评估学是一个崭新的跨学科的创新领域。法治评估学是法学和评估学的交叉学科。评估学已经发展成为涵盖评估指标、标准、评估方法、评估模型在内的一套理论体系。评估学已经在管理学、社会学、教育学等学科中,作为一种战略管理、目标管理、科学管理、政策分析的方法与工具,发挥对绩效状态的诊断、反馈作用,引导管理实践、社会实践、教育实践等活动。从《改革决定》可以发现评估机制的广泛应用。《改革决定》提出“发展成果考核评价体系”、“国家科研资源管理和项目评价机制”、“公共文化服务绩效考核机制”、“社会稳定风险评估机制”、“干部考核评价制度”等多类评估考核机制。从某种意义上说,科学评估代表了科学管理的一种方向。法治评估学是评估学渗入管理学、社会学后,在法学领域的拓展与延伸。这种渗透或者法学的跨学科研究,具体表现为国内外的各种法治评估实践。这种评估实践延伸拓展到了立法、司法等各个领域,出现了立法后评估、立法成本评估、

法治政府评估、案件质量评估、审判效率评估、司法透明指数、民间融资安全指数、食品安全指数等诸领域的评估活动。总体看,从中央到地方,从行政机关到司法机关,从理论界到实践界,都在探讨、实践对于公权力限制、信息公开、私权利保护等内容的量化评估,法治评估已经开始融入中国改革,法治评估已经出现热潮,法治评估学的创立也是情势所然。

法治评估学的深化研究必须走在法治中国建设步伐的前面,否则法治评估的理论准备就跟不上时代要求。跨学科合作,是构建科学的法治评估学的必由之路。法治中国建设作为一个系统工程,必然通过大量数据体现出来。例如,司法改革要求所有案件的立案、分案、庭审记录、录音录像、文书制作、上诉案件电子卷宗移送等全部在网上进行,由此要求司法工作适应大数据、云计算、移动互联网发展大趋势,对海量司法数据进行分布式数据挖掘,必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。中国法学界长期缺乏数据观念,研究方法落后,单纯依靠自己的力量无法适应大数据时代,也无法完成建构科学的法治评估学的任务。在法治评估学领域,要改变传统的个体户式、作坊式的研究方法,要尽早实现法学、统计学、评估学、计算机科学、管理学、社会学等领域的团队合作研究。

(二) 通过实践升华法治评估理论

法治评估的理论升华必须主要通过实践实现。法学学科的实践性有“强”“弱”之分。法治评估理论表现出“强”实践性,这与法哲学、法制史、法律思想史等其他法学学科有明显区别。

法治评估之所以在世界范围得到推广应用,其最大优势在于它评估的不是书本上或者观念中的法治,而是“实践中的法治”、“行动中的法治”。国内地方法治指数的测评是对年度的法治建设状况、法治目标的实现程度进行测评,对法治存在的问题进行分析,并作为下一年度法治改进或者法治行动调整方案的现实依据。这样,法治评估就起到联结法治理想与法治现实的作用,评估的对象是现实中的法,评估的素材也取之于法治现实,法治的评估属于法治建设、法治运行实践的一个有机组成部分。

以“指标体系和考核标准”为核心内容的法治理解与纯粹理论研究中的法治论述存在区别,中国法治评估与国际上的法治评估所界定的法治内涵存在区别,区别的标准必须通过实践来检验。

法治评估理论的实践性是对《法治决定》“借鉴国外法治有益经验,但决不照搬外国法治理念和模式”的最好诠释。法治既是一个具有一定普遍规律的概念,也是一个具有其民族性、地域性、地方情境性的概念。法治建设是一个普遍性与特殊性如何取得均衡的问题。法治在认知上存在差异是必然的,在实践中存在差异就更为必然。世界法治发展进程中不同的法律移植现象和结果,以及各国形成迥异的法治样式,都充分说明了这一点。法治评估在世界范围内的兴起与推广,表明了评估方

法论的可通约性。但与此同时,中国法治评估与西方法治评估在指标构成、评估层次、评估目的、评估方法等方面表现出差异性和多样性。^①法治评估的国内外差异反映的是法治实践的差异。世界正义工程的全球法治指标框架体系是对西方法治政府体制的提炼,是西方宪政体制的缩写。而中国的法治评估更多采用的是“因地制宜”的个性化制定方案,结合中国法治现状创新出中国特色的法治指标体系以及“专家主导、政府支持”的第三方法治评估模式。^②“坚持从中国实际出发”,是《法治决定》确定的全面推进依法治国的基本原则之一,而法治评估的实践性正是该原则得到贯彻的体现。

实践和实践智慧是法治评估理论的学术源泉。法治评估理论的实践性与马克思主义的实践观、中国共产党的实践方针一脉相承,并且都在本质上直接指向“实践智慧”。从本质上说,实践智慧联结了对世界的解释与对世界的变革,展现为“应当做什么”的价值关切与“应当如何做”的理性追问的统一,其赋予智慧以实践品格。^③相比实践智慧在哲学、伦理学、政治学领域得到较早充分研究,其对法学的影响以及在法学领域的应用是相对滞后的。直到分析哲学、实践哲学渗入法学,法学从传统的规范分析、自然法学派逐步转向分析法学、实证法学、社会学法学、功利主义法学、现实主义法学时,法学研究才逐步彰显出“实践”的品格。从某种意义上讲,传统法学向现代法学的转型,也是法学的“实践”转型和“理性”转型。^④传统法学向现代法学的转型,越来越重视社会实践中的法治经验和法治效果。中国法学界一些学者表现出对“实践”、“实践理性”的关注,如张文显提出“实践中的法理学”,^⑤还有学者围绕“法与实践理性”、“实践法律观”、“实践法治”^⑥等问题

① 参见钱弘道、戈含锋、王朝霞、刘大伟:《法治评估及其中国应用》,《中国社会科学》2012年第4期;王朝霞:《法治评估与法治创新——基于浙江余杭实践的讨论》,《广西民族大学学报》2013年第4期。

② 参见钱弘道、戈含锋、王朝霞、刘大伟:《法治评估及其中国应用》,《中国社会科学》2012年第4期。

③ 参见杨国荣:《论实践智慧》,《中国社会科学》2012年第4期;郑永流:《实践法律观要义——以转型中的中国为出发点》,《中国法学》2010年第3期;武树臣、武建敏:《中国传统法学实践风格的理论诠释——兼及中国法治实践学派的孕育》,《浙江大学学报》2013年第5期;姚建宗:《中国语境中的法律实践概念》,《中国社会科学》2014年第6期。

④ 参见刘少杰:《康有为的实证精神及其制度社会学——依据康有为〈实理公法全书〉和〈大同〉的讨论》,《社会科学研究》2010年第5期。

⑤ 参见张文显:《书本的法理学与实践的法理学》,谢进杰主编:《中山大学法律评论》第8卷第2辑,北京:法律出版社,2010年,第93—104页。

⑥ 参见许传玺:《从实践理性到理性实践:比较、比较法与法治实践》,《浙江大学学报》2014年第5期;郑永流:《实践法律观要义——以转型中的中国为出发点》,《中国法学》2010年第3期。

进行探讨。法治评估理论是中国法学“实践”转型的一个突出代表。

针对法治评估理论这样的“强”实践性,一批学者尝试对法治评估进行学术阐述和理论概括。对法治评估的研究表现出与传统法学不同的方法,而且正在促使法学研究方法的转型。这种实证研究方法,在中国这个特定的场域,在中国转型期这样一个特定的时期,针对法治中国这样一个特定的范畴,在理论上会形成怎样一种认识模式?笔者探讨性地提出“中国法治实践学派”这个学术概念。这个概念是对法治评估实践的理论价值的提升,是探讨法治评估理论化转型的一个角度。中国法治实践学派,或者称为“法治实践的中国学派”,是以中国法治实践为研究对象,以探寻中国法治发展道路为目标,以创新中国法律制度和构建中国法治理论为具体任务,以实践、实证、实验为研究方法,注重现实和实效,构架具有中国特色、中国气派、中国风格的法治中国理论体系。通过中国法治实践学派这个概念,法治评估的方法、特征、实践和理论目标等要素可以得到比较恰当的融合。^①《法治决定》很好地表达了中国法治实践学派的任务:“围绕社会主义法治建设重大理论和实践问题,推进法治理论创新,发展符合中国实际、具有中国特色、体现社会发展规律的社会主义法治理论,为依法治国提供理论指导和学理支撑。”在世界范围内,完全可能出现一个不同于西方任何一个法学流派、以“中国法治实践”为问题导向的学派。法治中国伟大实践的成功、中国特色的社会主义法治理论的成熟、法学的繁荣、中国法学学派的出现,应当是同步的。围绕法治评估经验总结、理论概括和升华以及中国法治实践学派的具体内涵、主要特征、历史使命、理论支撑等内容,法学界已有一些学者进行了初步探讨。^②中国法治实践学派这个学术概念是否科学,学派形成究竟有多大可能性,如何推进学派的形成和发展,有待学术界深入讨论,更有待中国法治实践的发展来证明。这种探讨有益于法治评估的经验总结和理论升华转型。

(三) 法治评估研究方法常规化

法治评估研究范式的常规化是其理论升华的重要方面。如果在法学研究中运用法治评估研究范式成为一种自觉,那么,其方法论意义上的理论转型就得到了实现。法治评估在方法论上表现为实践性、实证性和实验性。这里需要区分实践、实证、实验三个词汇。实践,主要强调哲学基础,强调研究者要亲身参加实践,强调研究者的行动性;实证,强调具体问题的研究方法,与传统法学规范研究方法相对应;实验,是实证研究的一种方法,是将社会科学研究变成类似自然科学

① 参见钱弘道、王梦宇:《以法治实践培育公共理性——兼论中国法治实践学派的现实意义》,《浙江大学学报》2013年第5期。

② 参见钱弘道主编:《中国法治实践学派》。

的实验。法治评估研究范式的重要特征在于其与传统规范法学研究风格迥异的实证方法。从国内外的法治评估实践看,法治评估研究范式的主要特色在于采用量化方法和社会调查方法。^①从法学研究方法角度说,量化和社会调查方法都属于实证方法范畴。

量化法治是法治实践的最新表现形态,也代表着法治实践和研究的一种方向。^②有学者研究了新中国成立以来的法治认识的整个过程,认为中国的法治研究正从正名法治、定义法治转向量化法治,量化法治是法治认识的第三个阶段。^③以量化为主要特点的法治研究是对传统法学研究方法的一个重大冲击,正在引发法学研究方法的转型。法治评估在很大程度上推动了法学研究方法向实证法学的转型。这种转型的内容,就是以实证研究方法大量进入法学研究为标志。法学研究的实证转型又反过来推动法治评估的理论升华和实践优化。

实证研究是通过研究对象大量的观察、实验和调查,获取客观材料,从个别到一般,归纳出事物的本质属性和发展规律的一种研究方法。法学的实证研究倾向与现代化进程中的数字化管理、符号化运动所形成的“意义世界”有着直接的关联。随着自然科学的发展、计算机等技术手段的进步,定量分析方法在社会科学领域开始广泛运用。在这种背景下,人们开始不满足于过往那种抽象层面的定性的、模糊化的分析,开始注重精确化、客观化,在对人口、环境、经济、社会、政治、法治等人类社会问题进行考察分析时,开始着重于具体化的、细化分析,对其进展和发展状态进行定期的观测、考察、监督就成为一种需要。在这种需求下,过去那种基于理论层面的抽象分析和定性表述的局限性凸显,而亟需一种明确具体的、客观化的指标化表述,以及对指标表现水平的数字化描述。借助统计数据和模型,量化评估之风悄然兴起。

量化分析不是简单的数字化、数据化,而主要是指标化、绩效理念以及量化评估技术方法的恰当运用。法治的量化分析开启了对法律现象和法学问题的新认识。量化法治的研究,也是量化法学的实证研究。法学正出现一种量化法学的新趋势。法学研究进入量化实证研究阶段是与法治评估同步的,而法治评估则是近十年的事情。法治评估的兴起与发展带动了学界关于法学方法论的热烈讨论。这种讨论有望将量化法学、实证法学推向法学研究的前沿阵地,使得实证研究成为法学研究的一种常规方法。

① 定性研究在法治评估中虽然也较为常用,但属于法学研究的常规方法,所以这里重点分析量化方法和社会调查方法。

② 参见钱弘道、王梦宇:《以法治实践培育公共理性——兼论中国法治实践学派的现实意义》,《浙江大学学报》2013年第5期。

③ 张志铭、于浩:《共和国法治认识的逻辑展开》,《法学研究》2013年第3期。

法学的实证研究遇到的一个最大问题莫过于“客观性”。中国的法学实证研究受到质疑。^① 解决法学实证研究的客观性难题,证明法学实证研究方法客观性的存在可能及实现途径,将是法学研究实证转型的一个要害问题,^②也是法治评估理论化的要害问题。

实证研究中包括实验方法。实验方法在社会科学领域已经引起重视。在经济学领域有“实验经济学”,在法学领域也可以有“实验法学”。法治评估就是一种法学实验。法学研究方法的转型应当包括实验方法的运用。实验是自然科学研究通用的、普遍的研究方法,通过特定场景的设定,对事物的运动轨迹、发展特性和规律进行反复总结、实验,以在试错、纠错中完善理论,发现真问题,形成理论创新。在社会科学领域,研究的对象和问题是与人、社会有关的“活的物体”,虽然它无法像自然科学实验那样在实验室内完成,但是,这并不意味着社会科学研究不需要做实验、不可以做实验。相反,社会科学研究完全可以用实验的方式开展。科学主义视法律为社会现象的一个因子,或者一个内在变量,是可以如同其他社会因子一样,通过社会科学方法进行科学分析的。

法治评估属于社会科学实验。法治评估的理论假设是:法治是客观的,是可观的、可测的。法治评估的实验也正是依循这样一种研究假设,将一个法治区域作为一个实验室,作为一个区、市、省乃至中国社会文明与进步的一个缩影,由此开展实验活动。法治评估的实验,就是试图通过深入观察、调查、分析像余杭区、吴兴法院这样更小、更容易控制的场域,将实验结果结合到更大的结构中。

实验就是一个“试错”的过程。法治中国建设必须进行许多的渐进实验。法治实验会告诉我们,法治条件处于动态变化中,任何法治理论都必须根据法治条件的变化而变化。中国法治建设并无经验可循,以实验的方式、以探索性的姿态进行法治实验是有效方式。在法学研究中,这种解剖麻雀式的社会科学实验方法可以推广应用。实验方法将传统法学引向法学科学主义,现在有不少研究机构和大学建立了政策仿真实验室、社会模拟实验室、社会科学研究实验基地,如中国社会科学院法学研究所成立“法治指数实验室”,浙江大学建立“社会科学实验室”,中国法治研究院建立“法治指数实验室”。这是一种良好的学术发展趋势。^③

① 参见任岳鹏:《法的社会实证研究之能与不能》,《政治与法律》2009年第8期;程金华:《奢侈的学术时尚:法律实证研究》,《中国社会科学报》2012年5月9日,第A07版;唐应茂:《法律实证研究的受众问题》,《法学》2013年第4期。

② 参见钱弘道、崔鹤:《中国法学实证研究客观性难题求解——韦伯社会科学方法论的启示》,《浙江大学学报》2014年第5期。

③ 参见钱弘道:《中国法治实践学派的界定》,《浙江大学学报》2014年第5期。

结 论

综上,可得出如下结论:法治评估正面临转型。《改革决定》和《法治决定》的出台是法治评估转型最重要的标志性事件。《改革决定》和《法治决定》将对法治评估的认识置于国家治理体系和治理能力现代化的框架之中,并引导从法治评估机制、法治量化、法治评估理论等方面实现法治评估的转型。

虽然目前各地政府的自我法治考评仍然具有提高政府管理绩效的意义,但存在的缺陷较明显。第三方评估是法治评估发展的一个重要方向。要让各地“一把手”真正履行“第一责任人”职责,就必须实施法治评估责任制。开展法治评估工作,要鼓励创新实验,要实施竞争机制。在全国范围内,可以先行从顶层设计角度推出关于法治建设指标体系和考核标准的指导性意见,同时鼓励地方创新,逐步建立和完善法治建设指标体系和考核标准。通过借鉴国外经验,通过综合评估和专项评估相结合的方式,逐步破解法治量化难题。法治评估学将成为一个崭新的学科领域。在法治评估实践中,中国法治实践学派作为一种有益的学术探讨,是法治评估理论概括和升华的一个产物,也是对改革开放以来法治中国实践的一个理论回应。

〔责任编辑:刘 鹏 责任编审:赵 磊〕